

총 평

힘든 수험생활을 참아 내시고, 답안을 구성하시느라 대단히 고생하셨습니다.

모두에게 합격의 영광이 있기를 기원하며 금년도 민사소송법 문제에 대한 예시답안을 올립니다. 이러한 예시답안은 강사개인의 생각으로 출제자의 의도와 다를 수 있으며, 정답이 아님을 분명히 합니다.

참고로 본 강사 정리서인 단권화민사소송법의 관련 부분도 언급합니다. 사실 공부는 교수님의 저서를 가지고 하는 것이 당연한 기본이고, 강사서는 참고용으로만 활용하여야 함에도 마치 특정교재에만 기술되어 있는 것으로 호도하는 기존 강평을 본 적이 있고, 의외로 이러한 상술에 기만당하는 수험생이 많아 보여 이를 바로잡기 위함이지, 제 개인 교재의 홍보용이 아님을 바로 살피 주시기 바랍니다. 대한민국의 모든 민사소송법 교재는 수험생을 합격으로 인도하는데 부족함이 없습니다.

A-1문

설문 (1)에서는 경계확정의 소의 성질을 묻고 있는데, 원래 형성의 소는 법정주의에 따라 법규정이 있어야 허용되는 것이나, 우리 법은 토지경계에 대해서 다툼이 있는 경우에 법원의 판결로 경계를 정하여 달라는 내용의 소에 대하여 규정하고 있지 않지만 판례와 학설은 이를 허용하고 있으므로 그 성질에 대하여 확인소송설과 형식적 형성소송설의 다툼이 있습니다. 이를 적절히 언급하는 것이 핵심입니다. 나아가 형식적 형성의 소의 특징에 대하여 간략한 설명도 필수적으로 보입니다. (단권화민사소송법 3판 147면 / 민사소송법 쟁점정리 54면 참조)

설문 (2)에서는 공유자가 원고가 된 경계확정의 소나, 공유자를 피고로 한 경계확정의 소의 공동소송형태에 관하여 고필공설과 유필공설의 다툼을 잘 설명하는 것이 핵심입니다. (단권화민사소송법 3판 563면 / 민사소송법 쟁점정리 220면)

설문 (3)은 고유필수적 공동소송에서 일부 당사자적격자의 누락이 있는 경우 소의 적법성 여부와 그 보정방법을 기술하는 것이 핵심입니다. 특히 제68조의 요건을 명확히 하시는 것이 좋은 답안구성으로 보입니다. (단권화민사소송법 3판 569면 / 민사소송법 쟁점정리 216면)

A-2문

설문 (1)은 제183조에 규정된 송달장소가 아닌 곳에서의 보충송달이 적법한지 여부인데, 답안구성과 관련하여 송달장소, 송달방법을 언급한 후 기술하는 것이 중요했겠습니다. (단권화민사소송법 3판 325면)

설문 (2)는 공시송달과 추후보완에 대한 설명인데, 제451조 1항 10호와 혼동하여 재심을 구체책으로 언급하지 않는 것이 중요했습니다. 적법한 송달이므로 재심은 문제가 되지 않고 피고의 절차보장을 위한 추후보완상소가부와 그 요건을 검토하는 것이 핵심입니다. (단권화민사소송법 3판 318면 / 민사소송법 쟁점정리 126면)

B-1문

설문 (1)은 변론주의에서 말하는 사실이 주요사실이라는 것, 간접사실과의 구별, 구별의 효과를 언급한 후 설문에서 주요사실이 무엇인지 포섭하셔야 합니다. (단권화민사소송법 3판 318면)

설문 (2)는 20년간 점유계속이 주요사실이므로 그 기산점은 간접사실이라는 판례의 입장과 반대입장의 설명을 잘 실시하시면 됩니다. (단권화민사소송법 3판 232면 / 민사소송법 쟁점정리 101면)

B-2문

설문 (1)은 주신문에서의 유도신문의 적절성에 관한 문제로 현행 교호신문제도상의 증인신문의 문제점을 언급하고, 이러한 유도신문을 금지하는 규칙 제91조를 언급하면 됩니다. (단권화민사소송법 3판 378면)

설문 (2)는 불출석 증인에 대한 제재에 관한 문제인데 먼저 증인은 출석의무가 있음을 언급하고, 이러한 의무를 위반했을 때의 제재를 조문에 의거 언급하시면 됩니다. (단권화민사소송법 3판 371면)

A-1문 : 30점 경계확정의 소와 고유필수적 공동소송

형제인 乙, 丙, 丁은 부친 A가 소유하고 있던 X토지를 상속받았다. 그런데 X토지에 인접한 Y토지를 B로부터 매수한 甲이 Y토지를 측량한 결과, X토지로 인해 등기부상의 면적보다 부족함을 알게 되었다. 그리하여 甲은 X토지의 등기부상 명의자인 乙, 丙, 丁을 상대로 토지경계확정의 소를 제기하였다.¹⁾

(1) 이 소의 종류는?(10점)

(2) 이 공동소송의 유형은?(10점)

(3) 이 소송 중 소외 戊가 검사를 상대로 자신이 A의 혼인 외의 자임을 주장하며 제기한 인지청구소송에서 승소하여 확정되었음이 밝혀졌다. 이 경우 戊가 당사자로 되기 위한 방법은?(10점)

I. 설문 (1) : 형식적 형성의 소

1. 문제점

소의 판결신청의 성질·내용에 의하여 이행의 소, 확인의 소, 형성의 소 세 가지로 분류된다. 이 중 형성의 소는 판결에 의한 법률관계의 변동을 요구하는 소로서, 법적 안정성을 흔들기 때문에 명문의 규정으로 허용되는 경우에만 인정하는 것이 원칙이다. 그러나 우리 법은 토지경계에 대해서 다툼이 있는 경우에 법원의 판결로 경계를 정하여 달라는 내용의 소에 대하여 규정하고 있지 않지만 판례와 학설은 이를 허용하는데 이 소를 확인의 소로 볼 것인가, 아니면 형식적 형성의 소로 볼 것인지 견해의 다툼이 있다.

2. 경계확정의 소의 성질

(1) 학설의 태도

- 1) 확인소송설 : 경계확정의 소는 소유권의 범위의 확인을 구하는 소송이라는 견해이다. 경계는 다만 토지소유권의 한계로서의 의미를 가질 뿐이며, 경계가 명확해지면 쟁점인 소유권범위에 관한 분쟁이 수습된다는 것을 근거로 한다.
- 2) 형식적 형성소송설 : 경계확정소송은 경계에 대한 다툼이 있을 때 법원이 그 경계를 확정한다는 방식을 취하는 쟁송적 비송사건이나, 다만 소송절차를 통하여 판결에 의하여 경계를 확정한다는 형식을 띠게 되므로 형식적 형성의 소라는 견해로, 통설의 입장이다.

(2) 판례의 입장²⁾

대법원은 『토지경계확정의 소는 인접한 토지의 경계가 사실상 불분명하여 다툼이 있는 경우에 재판에 의하여 그 경계를 확정하여 줄 것을 구하는 소송으로서, 토지소유권의 범위의 확인을 목적으로 하는 소와는 달리, 인접한 토지의 경계가 불분명하여 그 소유자들 사이에 다툼이 있다는 것만으로 권리보호의 필요가 인정된다. 토지경계확정의 소에 있어서 법원으로서 원·피고 소유의 토지들 내의 일정한 지점을 기초점으로 선택하고 이를 기준으로 방향과 거리 등에 따라 위치를 특정하는 등의 방법으로 지적도상의 경계가 현실의 어느 부분에 해당하는지를 명확하게 표시할 필요가 있고, 당사자가 쌍방이 주장하는 경계선에 기속되지 아니하고 스스로 진실하다고 인정하는 바에 따라 경계를 확정하여야 한다』고 판시하여 형식적 형성소송설의 입장이다.

1) 2012년 제49회 변리사기출 A-1문 / 해설 이종훈 강사

2) 대법 1993.11.23, 93다41792·41808

(3) 검 토

토지경계에 대한 분쟁은 공익적 판단이 요구되므로, 당사자의 쟁송을 법원이 재량에 의하여 판결하여야 할 것이다. 따라서 형식적 형성의 소라 할 것이다.

3. 형식적 형성의 소의 소송상 취급

(1) 처분권주의의 배제

당사자가 구체적인 경계표시를 하여 경계확정의 소를 제기하여도 무방하나, 법원은 그와 같은 당사자의 신청에 구속되지 않는다. 나아가 소송 도중 당사자가 청구의 인낙이나 화해를 하더라도 법원은 이를 인정하지 아니하고 스스로 경계를 확정짓는다. 당사자의 합의에 따라 토지의 경계가 이동하는 것을 허용하는 것은 공익적 요소가 강한 토지경계에 반하기 때문이다. 또한 불이익변경금지원칙도 배제되므로 항소법원은 제1심법원의 경계확정에 불복하여 항소한 자에게 불리한가의 여부를 불문하고 스스로 정당하다고 생각하는 경계를 다시 확정할 수 있다. 그 결과 부대항소를 하지 않은 피항소인에게 유리한 경계가 정해질 수도 있다.

(2) 원고청구기각 불가

법원은 원고가 신청한 경계가 법원의 판단과 다른 경우 원고청구를 기각할 수 없고, 반드시 진실한 경계를 찾아 경계선을 확정하여야 한다.

(3) 청구취지의 기재방법

경계확정을 신청하는 당사자는 청구취지에서「X 토지와 Y 토지의 경계확정을 구한다」라고 표시하고, 청구원인에서 X 토지와 Y 토지가 인접하고 있다는 사실과 그 경계가 불분명한 것을 주장하는 것으로 족하다. 즉 청구취지의 기재를 명확하게 할 필요가 없고 법원의 재량권의 기초만 나타나면 충분하다.

II. 설문 (2) : 공유자측을 상대로 한 경계확정소의 형태

1. 문제점

甲이 X토지의 등기부상 명의자인 乙, 丙, 丁을 상대로 제기한 토지경계확정의 소는 공유자들을 공동피고로 하여 제기한 것으로 권리의무가 공통한 관계에 해당하여 제65조의 주관적 요건은 갖추었고, 나아가 객관적 요건에도 문제가 없으니 공동소송의 요건은 갖추었다. 이하 이러한 공동소송의 형태를 검토한다.

2. 공동소송의 태양

공동소송은 공동소송인간에 합일확정이 필수적인가의 여부에 따라 통상공동소송과 필수적 공동소송으로 구분되며, 필수적 공동소송은 실체법상 관리처분권이 공동으로 귀속되어 소송공동이 강제되는 고유필수적 공동소송과 공동소송인 사이에 판결의 효력이 미쳐 합일확정이 요구되는 유사필수적 공동소송으로 구분된다.

3. 공유자를 상대로 한 경계확정의 소의 공동소송형태

(1) 견해의 대립

1) 고유필수적공동소송설³⁾ : 이웃 토지소유자와의 공유토지의 경계확정청구는 공유토지자

3) 이시윤 690면

체의 처분변경을 구하는 소이므로 소송수행권이 공유자전원에게 공동으로 귀속되기 때문에 (민법 제264조), 공유자 전원이 나서야 하는 고유필수적 공동소송이라는 견해이다.

- 2) 유사필수적공동소송설⁴⁾ : 경계확정의 소는 소유권확인이나 소유권이전등기의 청구와는 달리 공유자 중의 1인이 청구하거나, 1인에 대해 청구한다고 하여 지분에 한해서 경계가 정해진다는 일은 있을 수 없고, 1인이 청구하더라도 공유물 전체의 경계가 정해지는 것이다. 따라서 그 소송에서 당사자가 되지 않은 공유자는 그 판결의 효력을 받으므로 이런 경우는 유사필수적공동소송이라고 보는 것이 타당하다는 견해이다.

(2) 판례의 입장⁵⁾

대법원은 “토지의 경계는 토지소유권의 범위와 한계를 정하는 중요한 사항으로서, 그 경계와 관련되는 인접 토지의 소유자 전원 사이에서 합일적으로 확정될 필요가 있으므로, 인접하는 토지의 한편 또는 양편이 여러 사람의 공유에 속하는 경우에, 그 경계의 확정을 구하는 소송은, 관련된 공유자 전원이 공동하여서만 제소하고 상대방도 관련된 공유자 전원이 공동으로서만 제소될 것을 요건으로 하는 고유필요적 공동소송이라고 해석함이 상당하다”고 하여 고유필수적공동소송설의 입장이다.

(3) 검토 및 설문 (2)의 해결

생각건대 공유자 1인이 청구를 하더라도 공유물 전체의 경계가 정해진다는 논리적 근거가 무엇인지 불분명할 뿐만 아니라, 공유자 1인이 나머지 공유자가 가지는 실체법상 관리처분권을 행사할 수도 없다 할 것이어서 고유필수적 공동소송설이 타당하다.⁶⁾

Ⅲ. 설문 (3) : 고유필수적 공동소송에서 누락당사자 보정방법

1. 문제점

설문에서 소송 중 戊가 인지청구소송을 통해 새롭게 상속인으로 밝혀졌는데, 설문 (2)에서 검토한 바 甲이 제기한 경계확정의 소는 고유필수적 공동소송으로서 피고 측에 戊가 누락되어 피고적격자의 흠결이 있는 경우 소가 적법한지, 부적법하다면 보정방법이 문제된다.

2. 고유필수적 공동소송에서 당사자적격자의 누락

소송공동이 강제되는 고유필수적 공동소송에 있어서는 공동소송인으로 될 자를 한 사람이라도 누락한 때에는 소는 당사자적격의 흠결로 부적법하게 된다.

3. 보정방법

(1) 별소제기 변론병합

甲은 누락된 戊를 상대로 별소를 제기하고 법원이 변론을 병합하면 당사자적격의 흠결은 치유되는데, 병합을 하기 위해서는 ① 같은 종류의 소송절차로 심판될 것에 한하며(제 253조 참조), ② 각 청구 상호간에 법률상의 관련성이 있을 것을 요한다. 사안처럼 공동소송의 주관적 요건을 갖추었으면 이러한 관련성이 인정된다.

(2) 고유필수적 공동소송에서 추가

- 1) 의 의 : 고유필수적 공동소송에서 공동소송인으로 될 자를 일부 누락한 채 소를 제기하여

4) 호문혁 755면

5) 대법 2001. 6.26, 2000다24207

6) 김홍엽 770면

당사자적격이 갖추어지지 아니한 경우 제1심 변론종결시까지 원고의 신청에 따라 누락된 원고 또는 피고를 추가할 수 있는데(제68조), 이는 추가적 형태의 임의적 당사자변경이다.

- 2) 요 건 : ① 고유필수적 공동소송인 가운데 일부가 누락되었을 것, ② 공동소송의 일반요건을 갖출 것, ③ 추가된 당사자는 원고측이든 피고측이든 상관 없으나 원고의 추가에는 추가될 신당사자의 동의를 얻을 것(제68조 제1항 단서), ④ 제1심의 변론종결 전일 것, ⑤ 원고의 신청이 있을 것을 요한다.
- 3) 절 차 : ① 고유필수적 공동소송인의 추가도 새로운 소의 제기라고 할 수 있으므로 신청서에 추가될 당사자, 법정대리인 및 추가신청이유를 기재하여 법원에 제출하며, ② 법원은 이에 대하여 결정으로 허가여부를 재판한다(제68조 제1항). 허가결정을 한 때에는 허가결정의 정본을 당사자 모두에게 송달하여야 하며, 추가될 당사자에게 소장부분도 송달하여야 한다(제68조 제2항). ③ 허가결정에 대하여 이해관계인은 추가될 원고의 동의가 없었다는 것을 사유로 하는 경우에만 즉시항고를 할 수 있고(제68조 제4항), 신청을 기각한 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(제68조 제6항).⁷⁾
- 4) 효 과 : 고유 필수적 공동소송인의 추가가 허용된 경우에는 처음의 소가 제기된 때에 추가된 당사자와의 사이에 소가 제기된 것으로 본다(제68조 제3항). 나아가 종전의 필수적 공동소송인의 소송수행결과가 유리한 소송행위인 경우에 추가된 당사자에게도 효력이 미친다.

(3) 戊의 공동소송참가

소송의 목적이 한쪽 당사자와 제3자간에 합일적으로 확정될 필요가 있는 필수적 공동소송으로 될 경우 판결의 효력을 받는 자는 제83조 공동소송참가를 할 수 있다. 이 경우 유사 필수적 공동소송으로 될 경우뿐만 아니라 고유 필수적 공동소송으로 될 경우도 포함된다고 보아야 할 것이다. 다만, 고유 필수적 공동소송에 있어서 공동소송인의 일부가 누락된 경우 필수적 공동소송인의 추가규정에 의하여 당사자적격의 흠을 치유할 수 있으므로(제68조) 공동소송참가를 인정하는 실익이 있는가가 문제될 수 있다. 공동소송참가는 제68조의 규정에 의한 필수적 공동소송인의 추가와는 달리 항소심까지 허용되므로 여전히 탈락자 보충을 취한 제도로서의 실익이 있다.

7) 이점이 통상항고만 가능한 피고경정과 다르다.

A-2문 : 20점 보충송달 / 공시송달과 추후보완

오지여행을 취미로 하던 乙은 아프리카 여행을 준비하면서 여행자금이 부족하자 선배인 甲에게서 금 1,000만원을 빌렸다.⁸⁾ (각 문제는 별개로 봄)

(1) 乙이 그 여행을 다녀온 후 대여금의 변제기가 도래했음에도 불구하고 다니던 회사도 퇴사하고 연락도 되지 아니하며 갚을 생각도 하지 않자 甲은 乙을 상대로 대여금청구소송을 제기하였다. 피고 乙에게 소장과 제1회 변론기일 통지서를 송달하기 위해 우편집배원이 乙의 주소지에 갔으나 만나지 못해 우체국창구에서 찾아갈 것을 내용으로 하는 통지문을 남겼다. 이를 본 乙의 동거자 丙이 우체국창구에 찾아오자 당해 서류를 丙에게 교부하였다. 이것은 적법한가?(10점)

(2) 서울에 사는 甲이 乙의 주소를 알 수 없어서 乙에 대한 소장부분 등 소송서류를 법원의 명령을 받아 공시송달하였고, 그 결과 乙은 변론에 출석하지 못하여 甲은 승소하였고 판결은 확정되었다. 그런데 몇 달 후 乙이 1년간의 아프리카 여행에서 돌아온 후 甲이 자신에 대해 소송을 서울에서 제기하였고 소송서류를 공시송달로 하였음을 비로소 알게 되었다. 이 경우 귀책사유 없는 피고 乙에 대한 구제방법은?(10점)

Ⅰ. 설문 (1) : 보충송달의 적법성

1. 문제점

설문에서 소장과 변론기일통지서가 송달장소 이외의 곳에서 소송서류의 명의인이 아닌 동거자에게 교부된 것으로 보충송달로서 적법요건을 갖추었는지 문제된다.

2. 송달의 의의와 방법

(1) 의 의

송달이라 함은 당사자와 기타 소송관계인에게 소송상 서류의 내용을 알 수 있는 기회를 주기위해 법정의 방식에 따른 통지행위이며, 재판권의 한 작용이며 당사자의 입장에서는 절차적 기본권의 보장이라는 기능을 가진다.

(2) 송달할 장소

- 1) 주소 등에의 송달(제183조 1항) : 송달은 받을 사람의 주소·거소·영업소 또는 사무소에서 한다. 여기의 영업소 또는 사무소는 그 자신 경영의 개인영업소 또는 사무소만을 뜻하지 그가 경영하는 회사의 공장은 해당되지 않는다.⁹⁾
- 2) 근무장소에의 송달(제183조 2항) : 송달은 받을 사람의 주소 등을 알지 못하거나 그 장소에서 송달할 수 없는 때에는 송달받을 사람의 고용·위임, 그 밖에 법률상 행위로 취업하고 있는 다른 사람의 주소 등 즉 ‘근무장소’에서 송달할 수 있다. 그러나 소장, 지급명령서 등에 기재된 주소 등에 송달을 시도하지도 아니한 채 근무장소로 한 송달은 무효이다.¹⁰⁾
- 3) 만나는 장소에서의 송달(제183조 3항, 4항) : 송달받을 사람의 주소 등 또는 근무장소가 국내에 없거나 알 수 없는 때 또한 주소 등 또는 근무장소가 있는 사람의 경우에도 송달받기를 거부하지 아니하면 만나는 장소에서 송달할 수 있다. 이를 출회송달 또는 조우송

8) 2012년 제49회 변리사기출 A-2문 / 해설 이종훈 강사

9) 대법 2004.7.21, 2004마535

10) 대법 2004.7.21 2004마535

달이라 한다.

(3) 송달의 법정방식

민사소송법은 송달받을 사람에게 직접 서류의 등본 또는 부분을 교부하는 방법인 교부 송달을 원칙으로(제178조 1항) 기타 보충송달(제186조 1항, 2항), 유치송달(제186조 3항), 우편 송달(제187조)과 공시송달(제194조)을 규정하고 있다.

3. 보충송달의 적법요건

(1) 보충송달의 의의

송달장소에서 송달받을 자를 못 만났을 때에 다른 사람에게 대리송달하는 경우로서 ① 주소·거소·영업소·사무소에서 송달받을 사람을 만나지 못한 때에는 그 사무원, 피용자 또는 동거인으로서 사리를 분별한 지능이 있는 사람에게 서류를 교부할 수 있고(제186조 제1항), ② 근무장소에서 송달받을 사람을 만나지 못한 때에는 송달을 받아야 할 사람이 고용·위임·그 밖의 법률상 행위로 취업하고 있는 다른 사람 또는 그 법정대리인이나 피용자 그 밖의 종업원으로서 사리를 분별할 지능이 있는 사람이 서류의 수령을 거부하지 아니하면 그에게 서류를 교부할 수 있다(제186조 제2항).

(2) 송달장소 아닌 곳에서의 보충송달

이러한 보충송달은 제183조에서 정하는 ‘송달장소’에서 하는 경우에만 허용되고, 송달장소가 아닌 곳에서 사무원, 고용인 또는 동거자를 만난 경우에는 그 사무원 등이 송달받기를 거부하지 아니한다 하더라도 그 곳에서 그 사무원 등에게 서류를 교부하는 것은 보충송달의 방법으로서 부적법하다. 판례도 우체국 창구에서 송달받을 자의 동거자에게 송달서류를 교부한 것은 부적법하다고 하였다.¹¹⁾

4. 설문 (1)의 해결

설문에서 소장부분과 변론기일 통지서가 丙에게 우체국에서 교부된 것은 부적법하다. 다만 乙이 이에 대해 이의권을 행사하지 않으면 이의권의 포기·상실의 대상이 된다.¹²⁾ 그러나 기일통지를 받지 못해 乙이 출석할 수 없었기 때문에 패소판결을 받았다면 기일에 정당하게 대리되지 않은 사람에 준하여 상소나 재심에 의하여 구제되어야 한다.

II. 설문 (2) : 공시송달과 추후보완

1. 문제점

기간의 해태란 당사자나 기타의 소송관계인이 행위기간 내에 하여야 할 소정의 소송행위를 하지 아니하고 그 기간을 넘긴 것을 말한다. 설문은 공시송달 절차에 의하여 판결이 선고되

11) 대법 2001.8.31, 2001마3790; 이 사건 기록에 편철된 우편송달보고서에 의하면 재항고인에 대한 주소보정명령의 등본은 재항고인 본인이 아니라 그의 동거자인 김정예에게 교부되었는데, 이는 재항고인의 주소, 거소, 영업소 또는 사무실 등 민사소송법 제170조(현 제183조) 제1항에서 정하는 ‘송달장소’에서 이루어진 것이 아니라, 충북 청원군 현도면 소재 현도우체국 창구에서 이루어진 것임을 알 수 있으므로 이는 부적법한 보충송달이라 할 것이고, 이 사건 기록상 위 주소보정명령이 다른 상당한 방법에 의하여 재항고인에게 고지되었다고 볼 아무런 자료도 없으므로, 위 주소보정명령이 재항고인에게 적법하게 고지되었음을 전제로 하여 그 명령에서 정한 기간 내에 재항고인이 주소보정을 하지 않았다는 이유로 항소장을 각하한 원심재판장의 명령은 위법하다고 하지 않을 수 없다.

12) 대법 1984.4.24, 82므14

었고, 상소기간도 도과되어 확정되었다. 그러나 乙은 甲의 제소조차 인지하지 못했던 것으로 귀책사유가 없는데도 판결이 확정되는 치명적인 불이익을 입게된 바, 그 구체책이 문제된다.

2. 소송행위의 추후보완

(1) 의 의

당사자가 책임을 질 수 없는 사유로 말미암아 불변기간을 지킬 수 없어, 하여야 할 행위를 할 수 없었던 경우에 그 사유가 없어진 날부터 2주 이내에 게을리 한 소송행위를 보완할 수 있는 것을 말한다(제173조).

(2) 추후보완의 요건

- 1) 불변기간의 도과 : 불변기간이 아닌 나머지 기간은 늘이거나 줄일 수 있는 것이 원칙으로(제172조 1항·3항) 추후보완의 대상이 되지 않는다.
- 2) 불귀책사유 : 불변기간의 도과가 당사자가 책임질 수 없는 사유로 말미암은 경우, 즉 귀책사유가 없는 경우여야 한다. 이것은 불가항력에만 한하는 것이 아니고 일반인의 주의와 능력을 다하여도 피할 수 없었던 사유를 말한다.

(3) 추후보완의 신청

추후보완을 하려면 추후보완을 해야 할 자가 해태한 소송행위를 그 본래의 방식으로 하면 되고 따로 추후보완을 신청할 필요는 없다. 해태된 본래의 소송행위에 추후보완사유의 주장, 입증이 있어야 한다.

3. 공시송달과 추후보완

(1) 인정되는 경우

공시송달의 경우에는 상소추완을 불허하면 당사자에게 가혹하고, 허용하면 공시송달제도의 기능이 상실되므로 수송달자의 공시송달자체에 대한 부지 외에 무과실의 요건을 갖춘 때에 한하여 소송행위의 추후보완을 인정하여 양자를 조화시킨다. 따라서 소송이 처음부터 공시송달의 방법으로 송달되었다면 특별한 사정이 없는 한 피고가 책임질 수 없는 사유로 인하여 불변기간을 준수할 수 없었던 때에 해당하나, 처음에는 송달이 되다가 송달불능으로 공시송달에 이른 경우,¹³⁾ 당사자가 신고한 주소에 송달이 되지 않아 공시송달에 이른 경우,¹⁴⁾ 당사자가 소제기사실 등을 알 수 있었던 경우¹⁵⁾ 등은 당사자가 책임질 수 없는 사유에 해당하지 아니한다는 것이 판례이다.

(2) 추후보완기간

공시송달에 의한 판결의 송달사실을 과실 없이 알지 못한 경우에는 당사자나 대리인이 판결이 있었던 사실을 안 때가 아니라, 그 판결이 공시송달의 방법으로 송달된 사실을 안 때부터¹⁶⁾ 추후보완기간이 기산된다.

4. 설문 (2)의 해결

설문에서 乙은 장기간의 해외여행 중이었고, 책임질 수 없는 사유로 불변기간을 도과한 것으로

13) 대법 1998.10.2, 97다50152

14) 대법 1994.2.25, 93마1851

15) 대법 1987.9.8, 87다카1013

16) 대법 1994.12.13, 94다24229

로 보인다. 따라서 乙은 공시송달의 방법으로 판결이 확정된 것을 안 날로부터 2주내에 추후 보완항소를 제기할 수 있다. 다만 추후보완항소를 하더라도 불변기간 도과에 따른 판결의 형식적 확정력이 해소되지는 않으므로 甲의 확정판결에 따른 집행을 저지시키려면 제500조의 별도의 집행정지결정을 요한다.

B-1문 : 30점

주요사실과 간접사실의 구별

甲은 자기 소유의 토지를 乙(지방자치단체)이 도로로 점유하여 사용하고 있음을 이유로 부당이득반환청구를 하였다. 이에 대하여 乙은 이 토지를 1987.3.17.부터 20년 이상 점유하여 이를 시효취득하였다고 항변하였다. 乙의 항변에 대하여 甲은 당초 乙의 점유개시 시기를 乙의 주장과 같이 1987.3.17.이라고 하였다가 이후 2006.1.경부터 점유를 하였다고 하면서 그 주장을 변경하였다.¹⁷⁾

(1) 변론주의에서 말하는 ‘사실’은 무엇을 말하는가?(20점)

(2) 부동산의 시효취득에 있어서 점유기간의 산정기준이 되는 점유개시의 시기에 관한 甲의 위의 주장 사실은 어떤 사실인가?(10점)

I. 설문 (1) : 변론주의에서의 사실

1. 문제점

변론주의에서 말하는 사실이란 증거조사의 결과 법원이 인정한 사실과 당사자가 주장하는 사실에 차이가 생긴 경우에 법원은 당사자가 주장하지 않은 사실을 인정하고 판결의 기초로 하여도 무방한가를 묻는 것이다. 이하 변론주의의 의의를 검토하고 변론주의가 적용되는 사실의 의미를 살펴본다.

2. 변론주의의 의의와 적용범위

(1) 의 의

변론주의는 판결의 기초를 이루는 사실의 확정에는 필요한 소송자료의 수집·제출을 당사자의 권능 및 책임으로 하는 원칙을 말한다. 즉 법원은 당사자에 의하여 주장되지 않은 사실을 판결의 기초로 하는 것이 불가능하다.

(2) 적용범위

변론주의는 주요사실에 한하여 적용되는데, ① 주요사실이란 실무상 요건사실이라고도 하는 것으로 권리의 발생·변경·소멸이라는 법률효과를 발생시키는 법규의 직접 요건사실을 말한다. ② 간접사실은 주요사실의 존재를 추인하는데 도움이 됨에 그치는 사실이다. ③ 보조사실이란 증거능력이나 증거가치에 관한 사실을 말한다.

3. 주요사실과 간접사실의 구별

(1) 견해의 대립

- 1) 법규기준설 : 법률효과를 발생시키는 법규의 요건사실이 주요사실이고, 그 이외의 사실은 간접사실로 보는 견해로 종래 통설의 입장이다.
- 2) 중요사항주장설 : 법규기준설을 버리고 소송의 승패에 영향을 미치는 중요한 사실에 대하여는 변론주의의 적용이 있다고 보는 것이 타당하다는 견해이다.¹⁸⁾
- 3) 준주요사실설 : 법규기준설에 입각한 주요사실과 간접사실의 구별은 유지하되, 과실, 인과관계 등을 요건으로 한 일반규정의 경우만은 일반규정의 요건사실 자체를 변론주의의 적용을 받는 주요사실로 볼 것이 아니라 요건사실을 구성하는 개개의 구체적

17) 2012년 제49회 변리사기출 B-1문 / 해설 이종훈 강사

18) 전병서 교수님은 “소송에서 중요한 역할을 하는 간접사실에는 변론주의가 적용되고, 주요사실 가운데에도 소송에서 중요하지 않은 것에는 변론주의의 적용이 없다고 하면서 준주요사실설과 결론에서는 큰 차이가 없다”고 서술하고 있다(315면).

사실이 재판에서 중요한 역할을 함에 비추어 이러한 구체적 사실을 주요사실에 준해서 변론주의의 적용을 받게 하자는 견해이다.¹⁹⁾

- 4) 요건사실·주요사실 구별설 : 주요사실은 변론주의가 적용되는 사실로 당사자가 주장하고 법원이 심리해야 할 중요한 사실이고, 요건사실은 법원이 당사자가 구하는 법률효과를 인정하는 데에 필요한 사실이라고 보는 견해인데,²⁰⁾ 일반조항의 경우는 법적 평가인 요건사실에 해당하고 개개의 구체적 사실이 역사적 사실로서 주요사실이라고 본다.

(2) 판례의 태도²¹⁾

판례는 “민사소송절차에서의 변론주의 원칙은 권리의 발생·변경·소멸이라는 법률효과 판단의 요건이 되는 주요사실에 대한 주장·증명에 적용되는 것으로서, 그 주요사실의 준부를 확인하는 데 도움이 되는 간접사실이나 그의 증빙자료에 대하여는 적용되지 않는다”고 판시하여 법규기준설의 입장에서 구체적인 경우마다 주요사실과 간접사실을 구별하고 있다.

(3) 검토

생각건대 법규기준설은 i) 실제 소송에서 간접사실이 주요사실보다 더 중요한 기능을 하는 경우가 많다는 점, ii) 일반조항 자체를 주요사실로 보나 일반조항 자체를 주요사실이라고 하면 증명의 대상으로 직접 증명해야 하지만 이러한 일반조항은 관념적 법적평가이므로 직접 증명이 곤란하다는 점에서 문제가 있고, 중요사항주장설은 그 기준에 모호한 점이 있으며 따라서 해석자의 자의를 허용할 염려가 있어 문제되며, 요건사실·주요사실 구별설²²⁾도 설득력이 있으나 당사자에게 주장책임을 분배하는 가장 타당한 기준은 법규가 될 수밖에 없다는 점에서 종래의 법규기준설에 따른 주요사실과 간접사실의 구별을 유지하되, 일반조항의 경우에 한하여 그 내용인 구체적인 사실을 준주요사실로 보는 것이 타당하다고 본다.

4. 구별의 효과

(1) 사실의 주장책임

주요사실은 당사자의 주장이 있어야 판결의 기초로 삼을 수 있다. 그러나 간접사실은 당사자가 변론에서 진술한 바 없더라도 증언 등의 소송자료에 의하여 변론에 나타나면 판결의 기초로 삼을 수 있다.

(2) 자백의 구속력

간접사실에 대해서는 법관의 자유심증 문제상 자백의 구속력이 부정된다. 다만 문서의 진정성립에 관한 자백은 보조사실에 관한 것이나 자백의 구속력을 인정하는 것이 판례이다.

19) 이시윤 304면; 정동윤/유병현 315면; 이 견해에서는 과실은 법적 추론에 불과하므로 변론주의가 적용되지 아니하고 그 내용을 이루는 개개의 구체적 사실을 주요사실로 취급하므로 변론주의가 적용되고 당사자가 주장하지 않은 사실을 판결의 기초로 삼을 수 없다고 한다.

20) 호문혁 370면; 강현중 413면

21) 대법 2004.5.14, 2003다57697; 대법 2002.8.23, 2000다66133

22) 호문혁 370면에서는 준주요사실설은 과실 등에 있어서는 주요사실은 없고 준주요사실만이 있게 되는 이상한 결과가 된다는 문제가 있다고 하면서 과실 등 일반조항의 경우에는 이들 법적 평가나 권리 등이 요건사실이지만 변론주의가 적용되는 사항인 주요사실이라고 할 수는 없다고 본다. 왜냐하면 이는 변론주의는 사실에만 관계된 것이고, 법적 평가와는 관계가 없기 때문이며, 그러므로 과실이 요건사실이면 과실로 평가되는 행위, 즉 예컨대 음주운전, 과속운전 등이 주요사실이라고 본다.

(3) 유일한 증거

유일한 증거가 주요사실에 관한 것일 때 법원은 그 조사를 거부할 수 없다(제290조 단서). 간접사실에 관한 것일 때에는 그 조사를 거부할 수 있으나, 판례는 채무를 변제하였다는 증거로 제출한 서증이 유일한 증거이면 그 서증의 진정성립을 위하여 증인이 단 한번 출석하지 아니하였다 하여 취소한 다음 항변을 받아들이지 아니한 것은 채증법칙위반이라 하였는데,²³⁾ 주요사실에 대한 증거인 서증의 형식적 증거력에 주목한 판례로 보인다.

(4) 판단누락

주요사실에 대한 판단을 누락하면 제451조 1항 9호에 의해 상고·재심사유가 되나, 간접사실은 판단하지 않아도 판단누락의 위법이 없다.

(5) 증거조사의 필요성

주요사실은 증거에 의하여 인정해야 하나, 간접사실은 주요사실을 인정하기 위한 수단이기 에 주요사실과 무관하며 증거조사가 불필요하다.

5. 설문의 해결

설문에서 甲의 소유에 속한다는 사실, 손해가 발생하였다는 사실, 乙이 20년간 점유계속사실, 나아가 소유의 의사로 평온, 공연한 점유라는 사실이 주요사실로서 변론주의가 적용된다. 다만 이러한 사실은 반드시 주장책임을 지는 자의 주장이 있어야 하는 것은 아니고 어느 당사자이든 변론에서 주장하면 판결의 기초로 삼을 수 있다.

II. 설문 (2) : 취득시효기산점의 성질

1. 문제점

甲은 피고 乙이 주장한 취득시효 기산점에 대하여 다투지 않다가 이를 반복하였다. 만 일 취득시효 기산점이 주요사실이라면 재판상 자백이 성립하여 임의철회할 수 없으므로 기산일의 성질에 대하여 검토한다.

2. 취득시효 기산일의 경우

(1) 학설의 태도

① 법규기준설의 입장에서 취득시효를 규정한 민법 제245조의 규정에 의해 “20년간 부동산을 점유한 사실”이 주요사실이고, 그 기산점에 관한 규정은 없으므로 간접사실에 해당한다고 보는 견해와, ② 요건사실·주요사실 구별설의 입장에서 소멸시효나 취득시효 모두 기산점 자체는 권리의 취득이나 상실의 요건사실이 아니며, 요건사실은 시효기간이 이미 완성되었다는 사실이고, 시효의 기산점은 그것이 정해지면 계산상 바로 시효완성 여부가 정해지므로 주요사실에 해당한다는 견해의²⁴⁾ 대립이 있다.

(2) 판례의 입장

대법원은 『취득시효의 기산점은 법률효과의 판단에 관하여 직접 필요한 주요사실이 아니고 간접사실에 불과하여 법원으로서는 이에 관한 당사자의 주장에 구속되지 아니하고 소송자료에 의하여 진정한 점유의 시기를 인정하여야 하는 것』²⁵⁾이라 하여 간접사실로 보고 있다.

23) 대법 1962.5.10, 4294민상1510

24) 호문혁 317면

(3) 검 토

소멸시효에서는 시효기간이 경과함으로써 권리가 절대적으로 소멸하지만 점유로 인한 부동산취득시효의 경우 점유자가 등기까지 하여야 소유권을 취득하므로, 시효기간 완성 후 등기 전 제3자가 소유권이전등기를 마쳤다면 점유자는 소유권을 취득하지 못한다. 만약 취득시효의 기산점을 당사자가 임의로 선택할 수 있도록 하고, 법원이 당사자의 주장에 구속되어야 한다면 제3자가 취득한 이후에 점유기간이 완성된 것으로 기산점을 주장함이 가능하게 되어 등기 없이도 제3자에 대항할 수 있다는 결과가 되므로, 당사자가 주장한 기산점에 법원이 구속되지 않고 객관적인 점유 개시시를 잡을 수 있도록 간접사실로 보는 것이 타당하다고 보인다.

3. 설문 (2)의 해결

취득시효의 기산점은 간접사실로 보는 것이 타당하고, 따라서 甲이 피고 乙의 기산일 주장에 다툼이 없었다하여도 재판상 자백이 성립하는 것이 아니므로 甲은 기산일에 대한 새로운 주장이 가능하며, 법원도 이에 구속되는 것이 아니다.

25) 대법 1994.4.15, 93다60120; 이와 같은 판례의 입장에 대해서는 ① 민법 제166조에서는 소멸시효기산점에 관한 명문규정이 있는 반면, 민법 제245조에는 취득시효기산점에 관한 규정이 없고, ② 소멸시효기산점을 주요사실로 보더라도 제3자의 권리를 해할 우려가 없으나, 취득시효기산점을 주요사실로 보는 경우에는 취득시효 완성 후 소유권을 취득한 제3자의 권리를 해할 우려가 있기 때문이라고 평석되고 있다.

B-2문 : 20점 유도신문의 금지 / 증인불출석에 대한 제재

甲은 乙이 운전하는 차에 치어 중상을 입어서 乙을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하였다. 이 소송에서 乙은 그러한 사실이 전혀 없었다고 甲의 주장을 부인하자 甲은 그 사건을 목격한 丙을 증인으로 신청하였다. 증인신문에서 丙은 자신이 2011.5.30. 오후 2시경 횡단보도를 건너고 있는 중에 乙의 승용차가 甲을 치어서 길바닥에 쓰러뜨렸고, 乙이 차에서 내려 약 1분동안 甲을 살펴보는 것을 목격하였다고 증언하였다.²⁶⁾

- (1) 위에서 원고 甲이 丙을 신문하면서 “증인이 2011.5.30. 오후 2시경 횡단보도를 건너고 있는 중에 乙의 승용차가 甲을 치어서 길바닥에 쓰러뜨렸고, 乙이 차에서 내려 약 1분동안 甲을 살펴보는 것을 목격하였지요?”라고 물어보았다. 이에 丙은 “네”라고만 대답하였다. 이렇게 자신이 원하는 바대로 진술을 얻어내는 이러한 신문은 적절한가?(10점)
- (2) 만일 위 소송에서 丙이 정당한 사유 없이 출석하지 아니한 경우의 제재방법은 무엇이 있는가?(10점)

I. 설문 (1) : 증인신문의 적절성 여부

1. 문제점

증인신문의 방법에 관하여 민사소송법은 1961년 개정법률로써 신문의 주체를 법원에서 당사자로 옮겨 대륙식의 직권신문제를 버리고, 영미식의 교호신문제도를 채택하였다. 이하 현행 증인신문제도의 운영실태에 따른 설문의 신문방식이 적절한지 검토한다.

2. 교호신문제도

증인신문은 원칙적으로 증인신문의 신청을 한 당사자의 신문(주신문) → 상대방의 신문(반대신문) → 증인신문을 한 당사자의 재신문(재주신문)의 순으로 진행되고, 그 이후의 신문은 재판장의 허가를 얻은 경우에 한하여 허용되며, 재판장은 당사자에 의한 신문이 끝난 다음에 신문한다(제327조 1항, 2항, 규칙 89조). 다만 법원은 알맞다고 인정하는 때에는 당사자의 의견을 들어 위와 같은 원칙의 신문순서를 바꿀 수 있다(제327조 4항).

3. 증인신문제도의 운영실태

증인은 구체적인 경험사실을 법원에 보고할 것을 명령받은 사람임에도 불구하고, 주신문자는 자기가 바라는 답변을 그대로 증인신문사항으로 만들어 “....사실이 있는가?”, “...라는데 사실인가?”라는 식의 질문을 하고 증인은 이에 거의 천편일률적으로 “예”라고 답하고 있는 실정이며, 이것은 “사실이 있다”, “사실을 안다”는 식의 증언을 하게 하여 직접 경험사실인지, 전문사실인지, 의견인지의 구별을 모호하게 함으로써 증언의 가치에 대한 판단을 흐리게 하거나 재판장의 보충신문 또는 반대신문에서 이를 확인하게 하여 증인신문시간이 길어지게 하는 요인이 되고 있다.

4. 현행 법규상의 제재

(1) 주신문에서 유도신문의 금지

민사소송법 규칙은 제91조 제2항에서 ① 증인과 당사자의 관계, 증인의 경력, 교우관계 등 실질적인 신문에 앞서 미리 밝혀둘 필요가 있는 준비적인 사항에 관한 신문의 경우, ② 증인이 주신문을 하는 사람에 대하여 적의 또는 반감을 보이는 경우, ③ 증인이 종전의

26) 2012년 제49회 변리사기출 B-2문 / 해설 이종훈 강사

진술과 상반되는 진술을 하는 때에 그 종전 진술에 관한 신문의 경우, ④ 그 밖에 유도신문이 필요한 특별한 사정이 있는 경우외로는 주신문에서 유도신문을 금지하고 있다.

(2) 법원의 조치

재판장은 제2항 단서의 각호에 해당하지 아니하는 경우의 유도신문은 제지하여야 하고, 유도신문의 방법이 상당하지 아니하다고 인정하는 때에는 제한할 수 있다(규칙 제91조 제3항).

5. 설문 (1)의 해결

현재 위증이 일반화되다시피한 상황이라 판사도 증인의 증거가치를 낮게 보고 있어 증인신문은 되도록 빨리 끝내려는 생각으로 장황한 신문이나 유도신문을 적극적으로 제지않고, 반대신문을 오히려 부담스러워 하게 되어 증인신문이 요식절차화 하는 경향이 있다. 설문과 같이 주신문자가 원하는 증언을 유도하는 신문은 적절하지 않으므로 민사소송규칙 제91조 3항에 따른 조치를 적극적으로 행사하는 소송지휘가 요망된다 할 것이다.

II. 설문 (2) : 불출석 증인에 대한 제재

1. 문제점

우리나라의 재판권에 복종하는 사람이면 누구든지 증인으로서 신문에 응할 공법상의 의무를 진다(제303조 이하). 이러한 증인의무는 출석의무 · 선서의무 · 진술의무로 이루어져 있는데, 민소규칙은 제82조에서 증인이 채택된 때에는 증인신청을 한 당사자는 증인이 기일에 출석할 수 있도록 노력하여야 한다는 규정을 신설하였다. 그러나 이러한 일반적인 규정만으로는 증인의 출석확보에 한계가 있으므로 신법은 불출석 증인에 대한 제재를 한층 강화하였는데, 이러한 제재는 법원의 직권사항으로 이하 검토한다.

2. 증인의 출석의무

(1) 의 의

증인조사를 증인진술서 제출방식이나 증인신문사항 제출방식으로 하는 경우에는 채택된 증인에 대하여 출석요구를 하여야 하는데(규칙 제81조 2항), 기일통지 내지 출석요구서를 받은 증인은 그 지정한 일시·장소에 출석할 의무가 있다.

(2) 증인이 출석할 수 없는 경우

증인이 기일에 출석할 수 없을 때에는 그 사유를 밝혀 신고하여야 하며(규칙 제83조), 신고의무를 불이행하면 정당한 사유 없는 불출석으로 인정될 수 있다(규칙 제81조 1항 2호 참조).²⁷⁾ 증인이 질병 등 정당한 사유로 출석하지 못할 때에는 수명법관·수탁판사로 하여금 증인을 신문하게 할 수 있다(제313조).

3. 불출석 증인에 대한 제재

(1) 소송비용부담과 과태료의 부과

증인이 적법한 출석요구를 받고 정당한 사유 없이 출석하지 아니한 때에는 법원은 결정으로 소송비용의 부담과 500만원 이하의 과태료에 처할 수 있다(제311조 1항). 소송비용부담결정과 과태료부과결정은 수소법원의 재량인데 양자는 함께 부과할 수도 있고 택일적으로

27) 정당한 사유란 질병 · 관혼상제 · 교통기관의 두절 · 천재지변 등을 뜻하고, 출석요구서의 내용을 확인하지 아니하였거나 기일을 잊은 경우는 이에 해당하지 않는다(법원실무제요).

할 수도 있다.

(2) 감 치

법원은 증인이 과태료의 재판을 받고도 정당한 사유 없이 다시 출석하지 아니하는 때에는 7일 이내의 감치결정을 내릴 수 있다(동조 2항). 감치에 처하는 재판은 그 재판을 한 법원의 재판장의 명령에 따라 법원공무원 또는 경찰공무원이 경찰서 유치장·교도소 또는 구치소에 유치함으로써 집행한다(제311조 4항). 감치의 재판을 받은 증인이 감치의 집행중에 증언을 한 때에는 법원은 바로 감치결정을 취소하고 그 증인을 석방하도록 명하여야 한다(제311조 7항). 감치사유가 발생한 날로부터 20일이 지나면 감치재판개시결정을 할 수 없다(규칙 제86조 2항).

(3) 구 인

법원은 정당한 사유 없이 출석하지 아니한 증인을 구인하도록 명할 수 있다(제312조 1항). 구인에는 형사소송법과 형사소송규칙의 구인에 관한 규정을 준용한다(동조 2항).

4. 제재수단에 대한 불복

과태료나 감치의 결정에 대하여 즉시항고를 할 수 있는데 그 집행을 정지시키는 효력은 없다(제311조 8항).